

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8494/2563

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ส. กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 69

มาตรา 4 ให้คํานิยามคำว่า "ผู้ดำเนินการ" หมายความว่า "เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระทำการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง" เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการ โจทก์ย่อมมีภาระการพิสูจน์ว่า จำเลยทั้งสองกระทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง แต่พยานโจทก์คงมี ภ. พยานโจทก์ที่เบิกความว่าพยานเป็นผู้ตรวจอาคารที่เกิดเหตุ พบว่ามีการก่อสร้างผิดแบบ โดยพยานไม่ได้เบิกความว่าพบเห็นจำเลยทั้งสองเป็นผู้ก่อสร้างด้วยตนเอง และมี ก. เจ้าของอาคารที่ติดอยู่กับบ้านเกิดเหตุเบิกความแต่เพียงว่าเห็นจำเลยทั้งสองอยู่ด้วยในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ได้เบิกความว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารด้วยตนเอง พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการตามความหมายของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 จึงวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นแก่จำเลยทั้งสองตามมาตรา 69 มิได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, 31, 40, 41, 42, 65, 66 ทวิ, 67, 69 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และขอให้ปรับเป็นรายวันฐานร่วมเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้ รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ปรับรายวัน ฐานร่วมกันจัดให้มีหรือร่วมกันก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ปรับรายวันฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ ระงับการกระทำตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ปรับราย วนฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามมิให้บุคคลได้ใช้หรือเข้าไปใน ส่วนใด ๆ ของอาคารตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ถึงวันฟ้องคือวันที่ 11 สิงหาคม 2559 และนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ปรับรายวันฐานร่วมกัน ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้หรือถอนอาคารก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึงวันฟ้องและนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งเจ้า พนักงนท้องถิ่น กับขอให้นับโทษของจำเลยทั้งสองต่อจากโทษของจำเลยทั้งสองใน คดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2595/2559 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยทั้งสองในคดี ที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, 31 วรรคหนึ่ง, 40 (1) (2), 42, 65 วรรคหนึ่ง วรรค สอง, 66 ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง, 67 วรรคหนึ่ง วรรคสอง, 69 ประกอบประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่าง กัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร (ที่ถูกดัดแปลงอาคาร) โดยไม่ได้รับ

อนุญาต จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท กับปรับอีกคนละวันละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เป็นเวลา 104 วัน เป็นเงิน 10,400 บาท รวมปรับคนละ 20,400 บาท ฐานร่วมกันจัดให้มีหรือร่วมกันก่อสร้างอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท กับปรับอีกคนละวันละ 100 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นเวลา 1 วัน เป็นเงิน 100 บาท รวมปรับคนละ 10,100 บาท ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้การระงับการกระทำ จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท กับปรับอีกคนละวันละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เป็นเวลา 82 วัน เป็นเงิน 8,200 บาท รวมเป็นเงินคนละ 18,200 บาท ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่ก่อสร้าง จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท กับปรับอีกคนละวันละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 สิงหาคม 2559) เป็นเวลา 1,532 วัน รวมเป็นเงิน 153,200 บาท รวมปรับคนละ 163,200 บาท และนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารก่อสร้าง จำคุกคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท กับปรับอีกคนละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 จนถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 สิงหาคม 2559) เป็นเวลา 1,417 วัน รวมเป็นเงิน 151,700 บาท และนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมทุกกระทงแล้วจำคุกคนละ 10 เดือน และปรับคนละ 363,600 บาท ทางนำสืบของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 6 เดือน 18 วัน (ที่ถูกคือ 6 เดือน 20 วัน) และปรับคนละ 242,400 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง, 31 วรรคหนึ่ง, 65 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารให้ผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 1 เดือน 15 วัน และปรับคนละ 9,000 บาท ฐานร่วมกันดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 1 เดือน 15 วัน และปรับคนละ 9,000 บาท รวมสองกระทง คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 เดือน 30 วัน และปรับคนละ 18,000 บาท จำเลยทั้งสองรู้สำนึกในความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิด กรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยทั้งสองคนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 เดือน และปรับคนละ 12,000 บาท จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 (1) (2), 41, 42, 65 วรรคสอง, 66 ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง, 67 วรรคหนึ่ง วรรคสอง ยกฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับการกระทำ ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่ก่อสร้าง ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารก่อสร้าง ไม่ปรับบทเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 69 และไม่ปรับจำเลยทั้งสองเป็นรายวัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินโฉนดเลขที่ 33768 เป็นอาคารพักอาศัย ขนาดพื้นที่ 366 ตารางเมตร ไม่มีโรงจอดรถ เสาอาคารด้านหน้าทิศตะวันตกมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน 1.55 เมตร และผนังอาคารเป็นคอนกรีตทึบ แต่จำเลยทั้งสองก่อสร้างเสาอาคารด้านหน้าทางทิศตะวันตกห่างจากแนวเขตที่ดินเพียง 0.30 เมตร กะมีการตั้งเสาคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวหลังคาโครงเหล็กเป็นโรงจอดรถกว้าง 5.40 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.50 เมตร 1 หลัง เจาะช่องประตูขนาด 0.70 เมตร สูง 1.80 เมตร 1 แห่ง และติดตั้งกอนแก้วใส ขนาด 0.45 เมตร สูง 0.60 เมตร บริเวณผนังอาคารด้านทิศตะวันตก

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรกว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามใช้อาคาร คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข และคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารหรือไม่ เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามใช้อาคารและคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขหรือไม่ เห็นว่า คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 47 ทวิ บัญญัติว่า "การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว" มาตรา 47 ทวิ นี้ได้เพิ่มเติมขึ้นทั้งมาตราโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 ซึ่งในตอนท้ายของพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ว่า เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น แสดงว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในกรณีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องมีการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนทราบเสียก่อนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องได้รับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว เมื่อพ้นกำหนดสามวันที่มีการปิดประกาศดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงจะเป็นการกระทำที่จะถือว่าเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ การแจ้งคำสั่งตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 ทวิ จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การกระทำของผู้ฝ่าฝืนครบองค์ประกอบความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในข้อนี้โจทก์นำนางสาวภาสินี เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นายช่างโยธาชำนาญงานมาเบิกความถึงพฤติการณ์ในการทำความผิดของจำเลยทั้งสองโดยละเอียด โดยพยานเบิกความว่าได้ส่งคำสั่งให้จำเลยทั้งสองทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ ตรวจดูเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า เป็นไปรษณีย์ตอบรับการส่งหนังสือแจ้งคำสั่งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอน เพราะมีตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์

ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 ไกล่เคียงกับวันที่ลงในหนังสือแจ้งคำสั่งให้จำเลยทั้งสอง
รื้อถอน คือ 23 สิงหาคม 2555 เอกสารที่ส่งไปถูกส่งคืนผู้ฝากเนื่องจากไม่มารับ
ภายในกำหนด เฉพาะภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ที่จำหน้าซองว่า 15/12 นั้น ปรากฏว่า
ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีไปถึงจำเลยที่ 1 ทุกฉบับ หนังสือสัญญาขาย
ที่ดิน ภาพถ่ายประกอบคดี รวมทั้งในคำฟ้องโจทก์ต่างก็ระบุว่าจำเลยที่ 1 อยู่บ้านที่
เลขที่ 15/2 ซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับคำสั่ง
จึงเป็นได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นส่งหนังสือแจ้งคำสั่งไปยังจำเลยที่ 1 ผิดบ้าน เห็นว่า
คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องและนำสืบพยานว่าจำเลยทั้งสองฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวม 4 คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการก่อสร้าง
จัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามให้ใช้อาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข
และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร แต่โจทก์ไม่อ้างส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับการส่งคำ
สั่งที่ให้ระงับการก่อสร้างจัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งที่ห้ามใช้อาคาร และคำ
สั่งให้ดำเนินการแก้ไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้แก่จำเลยทั้งสอง ณ ภูมิลำเนาของ
จำเลยทั้งสองเป็นพยาน เมื่อตรวจดูบัญชีพยานโจทก์ในสำนวน ปรากฏว่าโจทก์ก็มีได้
ระบุอ้างเอกสารหนังสือการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับเป็นพยาน และฎีกาของโจทก์ก็ยอมรับว่าโจทก์ไม่อ้างส่งเอกสารหลัก
ฐานการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับสำหรับคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง
จัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารและคำสั่งห้ามใช้อาคารให้แก่จำเลยทั้งสอง ที่นางสาว
ภาสินีพยานโจทก์เบิกความว่า ดำเนินการส่งเอกสารหนังสือคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว จึงเป็นเพียงคำเบิก
ความที่ปราศจากพยานเอกสารที่สำคัญ คือไปรษณีย์ตอบรับมาเป็นพยานหลักฐาน
สนับสนุน ทำให้คำเบิกความของนางสาวภาสินีไม่น่าหนัก ขอบเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้
ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ส่งคำสั่งตามมาตรา 47 ทวิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว การที่จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบต่อสู่คดีในประเด็นนี้ ไม่อาจ

ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองยอมรับ เพราะคดีนี้มีใช้คดีแพ่ง มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าหาก โจทก์มิได้นำสืบพยานในประเด็นสำคัญที่โจทก์มีภาระการพิสูจน์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เป็นประเด็นที่ชัดเจนแล้ว โจทก์จะได้ประโยชน์โดยไม่ต้อง นำสืบพยานหลักฐานตามภาระการพิสูจน์ จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดมา โจทก์ ยังมีภาระการพิสูจน์ว่ามีการกระทำความผิดจริงและจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความ ผิดนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 แต่เมื่อโจทก์นำสืบ ไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ปฏิบัติไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 47 ทวิ อย่างครบถ้วน การแจ้งคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อน ย้ายอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไข จึงเป็นการไม่ชอบ ถือ ไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองทราบคำสั่งดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานฝ่าฝืนคำ สั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่ง ให้ดำเนินการแก้ไข

ปัญหาต่อไปจะได้วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือไม่ คดีได้ความจากนางสาวภาสินีพยาน โจทก์ว่า เมื่อมีการตรวจสอบอาคารของจำเลยทั้งสองแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า เจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการ ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการ แก้ไขซึ่งเป็นการออกคำสั่งตามมาตรา 40 การที่จะให้คำสั่งดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ เจ้า พนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แต่เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการให้ครบถ้วน โดยไม่ได้ส่งหนังสือให้แก่ จำเลยทั้งสองทางไปรษณีย์ตอบรับ ทำให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคาร เพราะตามมาตรา 42 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอำนาจให้ เจ้าของอาคาร รื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ แจ้งคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขแล้ว แต่เจ้าของอาคารไม่ดำเนินการภายในกำหนด

เมื่อฟังข้อเท็จจริงว่ากระบวนการแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้จำเลยทั้งสอง ระวังการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่งให้ ดำเนินการแก้ไข ไม่ครบถ้วนมาตรา 47 ทวิ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองทราบคำสั่ง จำเลยทั้งสองไม่มีโอกาสดำเนินการแก้ไขได้ ดังนั้นการออกคำสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารนั้นจึงไม่อาจกระทำได้ แม้จะฟังว่าได้มีการแจ้ง คำสั่งให้รื้อถอนนี้เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้จำเลยทั้งสอง ณ ภูมิลำเนาของจำเลยทั้งสอง และได้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น ได้ง่าย ณ อาคารของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 47 ทวิ แล้วก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งให้รื้อถอนเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ การที่ จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีความผิดฐานฝ่าฝืนคำ สั่งให้รื้อถอน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระวังการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อน ย้ายอาคาร ฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามใช้อาคาร คำสั่งให้ ดำเนินการแก้ไข และฐานร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอน อาคารมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อไปว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 หรือไม่ ศาลฎีกา โดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าตามมาตรา 4 ให้คำนิยามคำว่า "ผู้ดำเนินการ" หมายความว่า "เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระทำ ดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง" เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการ โจทก์ย่อมมีภาระการพิสูจน์ว่า จำเลยทั้งสองกระทำ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง แต่พยานโจทก์คงมี นางสาวภาสินีพยานโจทก์ที่เบิกความว่า พยานเป็นผู้ตรวจอาคารที่เกิดเหตุพบว่ามี

การก่อสร้างผิดแบบโดยพยานไม่ได้เบิกความว่าพบเห็นจำเลยทั้งสองเป็นผู้ก่อสร้างด้วยตนเอง และมีนายเกียรติพล เจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับบ้านเกิดเหตุ เบิกความแต่เพียงว่าเห็นจำเลยทั้งสองอยู่ด้วยในระหว่างการก่อสร้าง ไม่ได้เบิกความว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารด้วยตนเอง พยานหลักฐานโจทก์ก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการตามความหมายของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 จึงวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ แก่จำเลยทั้งสองตามมาตรา 69 มิได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองไม่เป็นผู้ดำเนินการมานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง แต่บทบัญญัติดังกล่าวมีเพียงวรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องและความผิดตามมาตรา 21 นอกจากจะต้องวางโทษจำคุกและปรับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษปรับรายวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนด้วยตามมาตรา 65 วรรคสอง แต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้ลงโทษปรับรายวันนั้น แม้เป็นการไม่ถูกต้องแต่เมื่อโจทก์ไม่ได้ฎีกาในข้อดังกล่าว ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งสองต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, 31 วรรคหนึ่ง, 65 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ภัทรศักดิ์ วรรณแสง-ชัยรัตน์ ศิลาลาย-อำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล)

ศาลอาญา - นายพรชัย หวังประเสริฐกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล พันธุ์พัก

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------